

Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales -ITRC

DOLO / ELEMENTOS DE CONFIGURACIÓN – Modalidad de Culpabilidad

De esta manera, el derecho disciplinario, como derecho sancionador que es, exige la imputación subjetiva, que en punto de estructura de la falta disciplinaria implica la categoría de culpabilidad, siendo el dolo y la culpa las dos únicas modalidades de aquellas.

En cuanto a la primera (**Dolo**), los elementos para su configuración son los siguientes:

1. Atribuibilidad de la conducta (**imputabilidad**). En este punto es donde adquiere la regla disciplinaria su función de precepto de determinación. Así, quien no es determinable por la norma, resulta en causal de inimputabilidad o porque sencillamente no es sujeto disciplinable, no puede ser culpable.
2. Exigibilidad del cumplimiento del deber (**juicio de reproche**).
3. **Conocimiento** de la situación típica. Es decir, el conocimiento de los elementos estructurales de la conducta que realiza.
4. Conciencia de la ilicitud. Para que se dé esta se requiere el conocimiento de la prohibición o deber; es decir, el conocimiento del tipo disciplinario.
5. **Voluntad**, para realizar u omitir el deber o la prohibición.

FUENTE FORMAL: LEY 734 DE 2002 – ARTICULO 13

INTERPRETACIÓN NORMATIVA EN DERECHO DISCIPLINARIO – Diferencias de interpretación entre las partes no invalida por sí sola una decisión.

la Jurisprudencia Administrativa como Constitucional más recientes, han reconocido la interpretación y aplicación de la ley, como un pleno ejercicio propio de la autonomía funcionalmente conferida al servidor que tiene el poder disciplinario; entonces cuando éste adopta las decisiones interpretando y aplicando la ley, siguiendo su propio criterio, y con fundamento en los elementos de juicio y probatorios aportados al proceso, el control de legalidad del acto sancionador no autoriza per sé, la imposición de un criterio de interpretación y valoración diferente; ello sólo es posible en los casos en los que la decisión desborde protuberantemente los límites que imponen la Constitución y la ley.

Continuación del Fallo por el cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primera instancia proferido dentro del expediente disciplinario No. 1704-01-2014-041.

En consecuencia, las diferencias interpretativas entre lo expuesto en la decisión disciplinaria por parte del titular de la misma y la interpretación que adopte el procesado frente a los mismos asuntos probatorios, no constituyen por sí mismas razones suficientes para invalidar la decisión administrativa de primera instancia, así el hecho de que tal valoración no beneficie al recurrente, nada tiene que ver con la violación al debido proceso y al derecho de defensa.

FUENTE FORMAL: LEY 734 DE 2002 – ARTICULO 20

Dependencia:	Dirección General
Número del Proceso:	1704-01-2014-0041
Número y fecha del fallo:	00020 del dos (2) de julio de dos mil catorce (2014)
Asunto:	Fallo de segunda instancia
Criterio de Selección:	Fallo de primera instancia confirmado en segundo instancia

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede el despacho a resolver el recurso de apelación interpuesto por el abogado (XXX), en su condición de defensor de confianza del procesado (XXX), en contra del fallo sancionatorio proferido el pasado 19 de mayo de 2014 por la Subdirección Técnica de Investigaciones Disciplinarias de esta Agencia ITRC, dentro del expediente No.1704-01-2014-041.

COMPETENCIA

La suscrita Directora General de la Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales – ITRC, es competente para resolver la presente impugnación, en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto 4173 de 2011, aclarado por el Decreto 4452 de 2011, en atención a las previsiones contenidas en los numerales 12 y 13 del artículo 3° del Decreto 0985 del 14 de mayo de 2012, y al contenido del artículo 171 de la Ley 734 de 2002.

Continuación del Fallo por el cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primera instancia proferido dentro del expediente disciplinario No. 1704-01-2014-041.

HECHOS Y ANTECEDENTES PROCESALES

1.- Los hechos investigados en la presente actuación disciplinaria, tuvieron su origen en el informe de servidor¹ puesto en conocimiento de esta Agencia contra la corrupción UAE-ITRC, por la Subdirección de Control Disciplinario Interno de la UAE-DIAN², en el cual informó de presuntas irregularidades relacionadas con la posible falsedad de algunos documentos presentados por el servidor público (XXX), quien los presentara ante la entidad para tomar posesión del cargo como supernumerario en la coordinación de contabilidad de la UAE-DIAN, conforme lo dispuso la resolución de vinculación No.037 del 6 de enero de 2011³, para lo cual adjunto el funcionario formato de hoja de vida⁴ donde se anunció como contador público y en donde anexo diploma de contador publico expedido presuntamente por la universidad externado de Colombia⁵ y reproducción de la tarjeta profesional de contador No.29.499-T, expedida al parecer por la junta central de contadores a su nombre⁶.

2.- Con base en los anteriores hechos, mediante decisión del 24 de febrero del año en curso, la Subdirección Técnica de Investigaciones Disciplinarias de esta Agencia ITRC, dispuso decretar la apertura de indagación preliminar en contra del funcionario (XXX) ⁷.

3.- Con resolución 17412-002 del 22 de abril de 2014⁸, el despacho instructor calificó el mérito de las pruebas recolectadas en la etapa de indagación, formulando auto de cargos y citación a juicio verbal al funcionario (XXX), por su posible incursión a titulo doloso en la falta disciplinaria gravísima descrita en el numeral 56 del artículo 48 del Código Disciplinario Único, referente a *"Suministrar datos inexactos o documentación con contenidos que no correspondan a la realidad para conseguir posesión, en carrera administrativa" sic*; decisión notificada al procesado a través de apoderado el 28 de abril de 2014⁹ y frente a la cual presentó escrito de descargos, solicitando la

¹ Ver folios 1-4.

² Radicado 213-304-2013-333

³ Ver folio 14-17

⁴ Ver folio 9-13

⁵ Ver folios 4

⁶ Ver folios 5

⁷ Ver folios 96

⁸ Ver folios 135-139

⁹ Ver folio 141

Continuación del Fallo por el cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primera instancia proferido dentro del expediente disciplinario No. 1704-01-2014-041.

nulidad de la actuación por considerar que la imputación se basó en documentos copias sin autenticación, solicitud la cual fue denegada por el despacho a-quo¹⁰.

4.- En audiencia de juicio verbal del 19 de mayo de 2014¹¹, el despacho a-quo luego de escuchar en diligencia de versión libre al expedientado, practicar las pruebas decretadas y de correr traslado a los sujetos procesales para alegar de conclusión, profirió decisión sancionatoria en contra del funcionario (XXX), por encontrarlo disciplinariamente responsable a título de dolo del cargo previamente endilgado¹², imponiéndole como sanción la destitución e inhabilidad general para ejercer cargos públicos por el término de diez (10) años. En el proceso de dosificación de la sanción, atendiendo a la calificación de la misma, consideró el despacho de primera instancia viable la imposición de la sanción teniendo en cuenta en favor del disciplinado los criterios atenuantes del artículo 47 del CDU, en cuanto a la ausencia de antecedentes fiscales y disciplinarios del procesado, la diligencia en el desempeño del cargo y su confesión de la falta.

SUSTENTACIÓN DEL RECURSO

Dentro de la oportunidad procesal pertinente, esto es con la presentación del escrito de alzada datado el día 21 de mayo del 2014¹³, el defensor del procesado sustentó su recurso de apelación contra el fallo sancionatorio de primera instancia, solicitando de este despacho ad-quem, la absolución de su cliente, con base en los siguientes planteamientos:

Arguye el libelista que de ninguna manera se puede predicar la existencia del dolo en las actuaciones del encartado, pues *“si se entroniza en profundidad, estamos frente a aquella figura del dolo de ímpetu, que fue el que llevó a mi patrocinado a actuar de manera súbita, que se valora en lo moral, y obtiene su indulgencia para no alcanzar la perversidad delictual con que se refiere el acto de análisis procedimental” sic¹⁴*, señalando además que la conducta reprochada del expedientado no llevó a la entidad a ningún perjuicio o daño, porque cuando fue requerido por la entidad para cumplir unos requisitos para su nombramiento, ya la conducta del disciplinado era exaltada con ascensos y felicitaciones.

¹⁰ Ver folios 166-167

¹¹ Ver folios 186-193

¹² Artículo 48 núm. 56 de la ley 734 de 2002- Son faltas gravísimas: *“Suministrar datos inexactos o documentación con contenidos que no correspondan a la realidad para conseguir posesión, en carrera administrativa”*.

¹³ Ver folios 196

¹⁴ Ver folio 196

Continuación del Fallo por el cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primera instancia proferido dentro del expediente disciplinario No. 1704-01-2014-041.

Por lo anterior depreca que se tenga en cuenta tal calificativo en el sub examine sobre el dolo, para aliviar la dosificación de la sanción y suprimir la inhabilidad general, o en su defecto reducirla a (5) cinco años, atendiendo a que de no ser así, sería la muerte laboral o profesional del disciplinado, porque el Estado no emplea a personas mayores de 65 años y el disciplinado oscila por los 61 años de edad.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Previo a dar inicio a las consideraciones de instancia, es importante precisar que de conformidad con las prerrogativas normativas consagradas en el parágrafo del artículo 171 de la Ley 734 de 2002, "...El recurso de apelación le otorga competencia al funcionario de segunda instancia para revisar únicamente los aspectos impugnados y aquellos otros que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de la impugnación..."*sic*.

Como en el sub examine la impugnación se cierne sobre la presunta errada valoración del elemento subjetivo de la conducta analizada por el despacho a-quo, por la deprecada ausencia del dolo en la conducta por la cual fue sancionado el procesado; resulta entonces imperioso analizar el elemento subjetivo de la falta disciplinaria referente al dolo en el caso concreto, para determinar si en efecto esta se estableció con base en las pruebas obrantes en el plenario, en correspondencia y subvención con la ley y lo discernido por la jurisprudencia sobre el particular.

De conformidad con el artículo 13 de la Ley 734 de 2002, «En materia disciplinaria queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva. Las faltas solo serán sancionables a título de dolo o culpa».

En cuanto al dolo como elemento subjetivo e ingrediente estructural de la falta disciplinaria, la Procuraduría General de la Nación, recientemente ha señalado¹⁵:

"...El elemento subjetivo de la falta está formado por un juicio de «exigibilidad» y la acción del sujeto debe estar ceñida a la representación mental del deber indicado en la norma de derecho ha (sic) cumplir; por tanto, su inobservancia deberá estar atada al elemento volitivo

^{15 15} ORDOÑEZ MALDONADO, ALEJANDRO. *Justicia Disciplinaria De la ilicitud sustancial a lo sustancial de la ilicitud*, Bogotá, Instituto de Estudios del Ministerio Público de la Procuraduría General de la Nación, 2009, p. 25, 27 y 28.

Continuación del Fallo por el cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primera instancia proferido dentro del expediente disciplinario No. 1704-01-2014-041.

conformado por los ingredientes generadores del dolo o culpa; es por eso que «si la razón de ser de la falta disciplinaria es la infracción a unos deberes, para que se configure violación por su incumplimiento, el servidor público infractor sólo puede ser sancionado si ha procedido dolosa o culpablemente, pues, como ya se dijo, el principio de culpabilidad tiene aplicación no solo para las conductas de carácter delictivo sino también en las demás expresiones del derecho sancionador, entre ellas el derecho disciplinario de los servidores públicos...».

De esta manera, el derecho disciplinario, como derecho sancionador que es, exige la imputación subjetiva, que en punto de estructura de la falta disciplinaria implica la categoría de culpabilidad, siendo el dolo y la culpa las dos únicas modalidades de aquellas.

En cuanto a la primera (**Dolo**), los elementos para su configuración son los siguientes:

6. Atribuibilidad de la conducta (**imputabilidad**). En este punto es donde adquiere la regla disciplinaria su función de precepto de determinación. Así, quien no es determinable por la norma, resulta en causal de inimputabilidad o porque sencillamente no es sujeto disciplinable, no puede ser culpable.
7. Exigibilidad del cumplimiento del deber (**juicio de reproche**).
8. **Conocimiento** de la situación típica. Es decir, el conocimiento de los elementos estructurales de la conducta que realiza.
9. Conciencia de la ilicitud. Para que se dé esta se requiere el conocimiento de la prohibición o deber; es decir, el conocimiento del tipo disciplinario.
10. **Voluntad**, para realizar u omitir el deber o la prohibición.

Delimitados esos conceptos referentes al dolo en materia disciplinaria, la H. Corte Constitucional¹⁶ considera pertinente destacar las aproximaciones que se han hecho, desde la doctrina, a la definición del dolo en esta materia. La Corte destacó, en esa ocasión, la concepción elaborada por la Procuraduría General de la Nación al puntualizar:

“...El dolo en materia disciplinaria implica que el sujeto disciplinable haya tenido conocimiento de la situación típica que implica el desconocimiento del deber que sustancialmente debe observar y que voluntariamente haya decidido actuar en contravía

¹⁶ Sentencia C-1076 de 2002.

Continuación del Fallo por el cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primera instancia proferido dentro del expediente disciplinario No. 1704-01-2014-041.

de éste; por tanto, el conocer ya involucra de por sí el querer, ya que si se tiene conocimiento y pese a ello se realiza la conducta, es porque ciertamente se quiere el resultado...". [91]

La doctrina por su parte, ha propuesto partir de la definición que otras disciplinas¹⁷ hacen del dolo, asociándolo con la intencionalidad y el saber de la conducta, en términos similares a los citados planteamientos por la Procuraduría. Al respecto se ha dicho:

"...Tratándose del dolo en materia disciplinaria, se parte de una presunción, de estirpe Constitucional, consagrada en el artículo 122 de la Carta, según la cual el funcionario, al momento de asumir sus funciones, se compromete solemnemente a cumplir con la Constitución la ley y los reglamentos, que rigen la función o el servicio que va a desempeñar. Esto significa que entiende el compromiso que adquiere y que en consecuencia se obliga, no solo a observar las normas, sino a tener conocimiento de ellas y de la manera en que estas deben aplicarse(...) Por lo anterior se afirma que el servidor público soporta una mayor carga en materia de responsabilidad y que para excusarse de cumplir con sus postulados, debe probar, de manera fehaciente, que ha sido contra su querer o ajeno a su voluntad la actuación que vulnera el ordenamiento, o que su propósito fue diferente al conseguido, so pena de la correspondiente responsabilidad..."¹⁸.

Así las cosas y de conformidad con la Jurisprudencia acotada esta segunda instancia resolverá el caso concreto con fundamento en los siguientes criterios: i) El examen de la culpabilidad (elemento subjetivo) del servidor público investigado por la presunta comisión de una falta disciplinaria como requisito indispensable para sancionar; ii) determinar si el despacho a-quo en virtud del amplio margen para valorar si la falta se cometió a título de dolo o culpa, lo hizo dentro del marco dado por el sistema de "Numerus Apertus" establecido en materia disciplinaria; iii) verificar según la jurisprudencia citada si el dolo se configuro, en principio, cuando el disciplinable conoce la tipicidad de su conducta y, pese a ello, actúa en contra de sus deberes funcionales.

ANALISIS DE CULPABILIDAD DEL CASO CONCRETO

¹⁷ penal-policivo o contravenciones.

¹⁸ Procuraduría General de la Nación-Sala Disciplinaria Bogotá D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil doce (2012). Radicado 161 5274 (IUC-D-2009-792- 169941) -Aprobado en acta de sala n.º 07.

Continuación del Fallo por el cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primera instancia proferido dentro del expediente disciplinario No. 1704-01-2014-041.

Como se observa de la jurisprudencia en cita y de acuerdo con el artículo 13 de la Ley 734 de 2002, en materia disciplinaria las faltas sólo son sancionables a título de dolo o culpa.

Con base en el acervo probatorio legal y oportunamente allegado al expediente¹⁹, el despacho a quo enmarco la conducta del disciplinado, desde la perspectiva objetiva de la descripción típica del artículo 48 numeral 56 del CDU que a su tenor literal reza:

(...)Artículo 48. Son faltas gravísimas las siguientes:

Numeral 56. Suministrar datos inexactos o documentación con contenidos que no correspondan a la realidad para conseguir posesión, ascenso o inclusión en carrera administrativa (...).

En lo que respecta a la conducta típica endilgada al expedientado, es claro que en el presente asunto éste conjugo el verbo rector normativo - *"Suministrar datos inexactos"*, toda vez que probado se encuentra en el expediente²⁰ que el procesado presentó a la administración unos documentos (copias de diploma y de tarjeta profesional de contador público²¹) para, o con el fin de -*"conseguir posesión o ascenso en carrera administrativa"*, con consignaciones evidentemente apócrifas que claramente no podían ser reconocidas para tal fin, por no corresponder a la verdad.

A la anterior consumación se arriba por cuanto no fueron avaladas o acreditadas ni por la universidad externado de Colombia,²² ni por la junta central de contadores²³ tales documentos adjuntados por el procesado para llenar los requisitos propios para el efecto del ascenso y posesión del cargo como supernumerario Gestor II Nivel 302 Grado 02.²⁴

Documentos apócrifos plenamente conocidos por el investigado, esto es que sabía que estaba presentando ante la administración documentos falsos para el ascenso e ingreso a la carrera administrativa, pues según su propia versión de los hechos los mando a hacer por una cantidad de dinero en la carrera 13 con calle 45 de esta ciudad, en tal sentido manifestó *"...a pesar de que fui una vez y me dio miedo, pero ya era el 25 de enero y se me estaba agotando el tiempo para posesionarme, entonces volví al lugar y me contacte con una persona la cual me dijo que por una*

¹⁹ Ver folios 1, 4, 5, 9, 46, 48, 50, 56.

²⁰ Ver folios 4,5-8,16.

²¹ Ibídem.

²² Ver folio 50, 56 y 57.

²³ Ibídem.

²⁴ Ver folio 46

Continuación del Fallo por el cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primera instancia proferido dentro del expediente disciplinario No. 1704-01-2014-041.

cantidad de dinero podía conseguirme una fotocopia de esos documentos y dichas fotocopias fueron las que adjunte a la hoja de vida y con las cuales me poseione el 27 de 2011...sic.”²⁵

Si hasta este momento se analiza y valora de manera conjunta y sistemática en el contexto factico acreditado en el proceso, la situación probatoria de (XXX), es evidente y claramente indicativo que concurren múltiples hechos que lo comprometen en la conducta acusada como en lo ilícito de la misma y en la intensión dolosa de su actuar, posteriormente sancionada en la secuencia procesal que da cuenta el expediente; incurriendo en consecuencia y tal como lo valoro el despacho a-quo, en la conducta descrita en el artículo 48 numeral 56 del CDU referente a que el expedientado, *“Suministrar datos inexactos o documentación con contenidos que no correspondan a la realidad para conseguir posesión, ascenso o inclusión en carrera administrativa”*.

En tal sentido encuentra este despacho Ad-Quem, que el elemento subjetivo de la conducta disciplinaria se encuentra abastecido y adecuado a la imputación dolosa que hiciera el despacho a-quo en el presente asunto, como al sustento factico y probatorio que sobre el particular da cuenta la actuación disciplinaria, plenamente cimentada en la jurisprudencia arriba acotada sobre el carácter doloso de las conductas disciplinariamente relevantes, porque como se observó líneas atrás y tal como en el fallo impugnado lo considera el despacho de primer grado, la existencia del dolo en la realización de la conducta disciplinaria, se demuestra evidentemente en el actuar consciente, voluntario y auto determinado del disciplinado (XXX) en la realización de una conducta reprochable, elementos necesarios para materializar la realización dolosa de la falta disciplinaria.

Recuérdese que el comportamiento desplegado por el procesado es de aquellos que exigen para su realización el conocimiento, la conciencia y voluntad de su concreción, de tal forma que sobre la modalidad dolosa del elemento culpa, corresponde precisar que para el caso concreto, probado se encuentra que se reunieron a cabalidad tales elementos para su configuración (conocimiento de la ilicitud o antijuridicidad del comportamiento, y la voluntad de dirigir la acción hacia su materialización), de donde resulta que actúa dolosamente quien conoce los elementos esenciales del tipo(elemento cognitivo) y quiere con su conducta la acción y su resultado(elemento volutivo).

Dentro del anterior contexto, se ha entendido y explicado por el doctrinante de derecho disciplinario Carlos Arturo Gómez Pavajeau, que para que se materialice el dolo en materia disciplinaria, *“...basta que la persona haya tenido conocimiento de la situación típica aprehendida*

²⁵ Ver folio 163 adorso.

Continuación del Fallo por el cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primera instancia proferido dentro del expediente disciplinario No. 1704-01-2014-041.

en el deber que sustancialmente se ha infringido, y haya captado que le corresponde actuar conforme al deber. (...) El conocer ya involucra el deber, pues si conozco y realizo es porque quiero, lo cual ha sido pregonado por HRUSCHKA al sentenciar que "quien sabe lo que hace y lo hace, quiere hacerlo".

En conclusión, encuentra este sensor de instancia que el disciplinado no solamente tenía clara conciencia de la antijuridicidad de su conducta, sino que dirigió deliberadamente su voluntad a la violación de la ley administrativa para el acceso al escalafón de carrera administrativa y función pública²⁶ regentada sobre principios administrativos de orden Constitucional,²⁷ que con tal conducta, evidentemente resultan vulnerados, sin reparar en las exigencias propias del cargo. El dolo entonces aparece ostensible en el sub examine, en el entendido de que el comportamiento del disciplinado (XXX), expresó manifestaciones contrarias a derecho y a la recta función pública, por *"suministrar datos inexactos o documentos con contenidos que no correspondan a la realidad"* con el propósito de *"conseguir posesión, ascenso o inclusión en la carrera administrativa"*²⁸.

En tal sentido le asiste razón al despacho a-quo cuando señala que no se sanciona la comisión objetiva de una conducta punible del delito de falsedad (penal), sino la concreta disciplinariamente relevante, de suministrar a sabiendas de su mendacidad, datos inexactos con documentos con contenidos que no correspondan a la realidad para conseguir posesión en un cargo ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

A sí mismo no le asiste razón al recurrente, en cuanto a que es relevante para el tipo conductual endilgado doloso que el disciplinado buscará con su actuar causar un perjuicio a la administración, o pretendiera un provecho particular con su conducta; por cuanto el elemento del dolo para el caso concreto así no lo demanda.

Por el contrario y como se observa de las normas y la jurisprudencia arriba acotadas, lo que se protege en estos escenarios es la moralidad y la fé pública, pues por lo menos en forma potencial afecta el llamado tráfico jurídico y el principio de credibilidad y buena fe de los funcionarios en sus actuaciones, el suministrar datos o documentos mendaces para posesionarse en el escalafón de la

²⁶ Artículo 125 de la Constitución Política: El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes.

²⁷ Artículo 209 de la Constitución Política: La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.

²⁸ Artículo 48 numeral 56 de la ley 734 de 2002.

Continuación del Fallo por el cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primera instancia proferido dentro del expediente disciplinario No. 1704-01-2014-041.

carrera administrativa, por cuanto un empleado oficial que da fe de hechos que no tuvieron o han tenido existencia real para posesionarse en un cargo público, lesiona, con ese solo hecho, el bien que busca tutelar el ordenamiento jurídico punitivo, referente a la legalidad, credibilidad, transparencia y buena fe que se predica tanto en todas las actuaciones de la administración a través de sus agentes, como de los administrados²⁹, de allí que la normatividad disciplinaria sancione con rigor tal tipo de conductas mendaces, para posesionarse en carrera administrativa, al considerarlas gravísimas³⁰.

Por lo anterior comparte esta segunda instancia la exposición de motivos del elemento subjetivo de la conducta enrostrada al disciplinado por el despacho a-quo, en cuanto a que ésta se encuentra cimentada en sendas pruebas concernientes a que el señor (XXX) presentó información mendaz para posesionarse en un cargo para el cual no reunía requisitos, hechos probados y por demás reconocidos por el procesado, haciendo evidente el conocimiento de la ilicitud de su conducta gracias a su formación y amplia trayectoria laboral en la entidad, quien sin mayor esfuerzo podía comprender que la información que suministraba a la Dian para tomar posesión en un cargo público, debía ser verás y por demás sus anexos corresponder con la misma.

De otra parte debe recordarse sobre la facultad de autonomía e independencia administrativa, como el amplio margen del despacho a-quo que la ley y la jurisprudencia le reconocen al valorar si la falta se cometió a título de dolo o culpa y si se realizó dentro del marco dado por el sistema de "Numerus Apertus" establecido en materia disciplinaria, con base en los criterios señalados en los artículos 13 y 43 del CDU.

A este respecto se ha pronunciado la H. Corte Constitucional al precisar:

"(...)La prohibición de la conducta delictiva involucra un conjunto de patrones que establecen una precisión tipológica en la que se describen de manera detallada los elementos conformantes del tipo, de manera que, sujeto activo, conducta, intención, sujeto pasivo y circunstancias llevan en el procedimiento penal a una exhaustiva delimitación legal de las conductas; mientras que en la definición de las faltas disciplinarias, entran en juego, elementos propios de la función pública que interesan por sobre todo a contenidos político-institucionales, que sitúan al superior jerárquico en condiciones de evaluar con

²⁹ Artículo 83 de la Constitución Política: Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas.

³⁰ Artículo 48 numeral 56 del CDU.

Continuación del Fallo por el cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primera instancia proferido dentro del expediente disciplinario No. 1704-01-2014-041.

mayor flexibilidad, y de acuerdo con criterios que permiten un más amplio margen de apreciación, tal como lo ha entendido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos(...)
(Subrayas fuera de texto).

En el caso examinado, y según las pruebas que obran dentro del proceso, la actuación administrativa disciplinaria se surtió con plena observancia de las normas preexistentes y aplicables a la situación particular del impugnante, atendida la vigencia y obligatoriedad de las mismas.

A juicio de la Segunda Instancia, las exculpaciones ofrecidas por el recurrente para salvaguardar la responsabilidad disciplinaria de su cliente, no resultan atendibles. En efecto, es claro para este despacho que el señor (XXX) presentó información con documentación mendaz para posesionarse en un cargo para el cual sabía que no reunía requisitos, esto es para el cargo de supernumerario gestor II código 302, grado 02, suceso que se presentó el día 27 de enero de 2011 según el acta 0504 de fecha 27 de enero de 2011, obrante a folio 67 de esta actuación disciplinaria en la UAE-DIAN y materializó así tal como lo consideró el despacho a-quo, la descripción conductual del numeral 56 artículo 48 del ordenamiento disciplinario referente a “suministrar datos inexactos o documentación con contenidos que no correspondan a la realidad” con el propósito de “conseguir posesión, ascenso o inclusión en carrera administrativa”, a título de dolo.

De la apreciación conjunta sistemática y armónica de las pruebas que obran en el plenario y que realiza el despacho a-quo en el fallo de primera instancia visibles a folios 188 a 190, resulta evidente que se hicieron por el funcionario disciplinante dentro del ámbito de su autonomía y competencias, sin embargo el hecho de que tal valoración no beneficie al recurrente, en nada tiene que ver con violación de derechos de ninguna índole.

Al respecto de la valoración probatoria ha puntualizado el H. Consejo de Estado:

(...) Vale la pena precisar que en el ámbito de los procesos disciplinarios no existe una tarifa legal probatoria; de hecho el propio Código Disciplinario Único consagra, en su artículo 131, el principio de libertad probatoria, al establecer que “la falta y la responsabilidad del investigado podrán demostrarse con cualquiera de los medios de prueba legalmente reconocidos”. De manera que no es aceptable exigir que se haya recaudado un tipo determinado de pruebas –ejemplo un testimonio o documento- para efectos de sustentar

Continuación del Fallo por el cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primera instancia proferido dentro del expediente disciplinario No. 1704-01-2014-041.

un fallo disciplinario, que puede estar basado, por decisión expresa del Legislador, en cualquiera de los medios probatorios admitidos por el sistema legal Colombiano e incluso en otros medios probatorios, como se deduce del mismo artículo 130 ibídem³¹(...).

En ese orden de ideas, para la segunda instancia, el criterio de interpretación, valoración y aplicación normativa y probatoria que realizó el despacho a-quo, como órgano de control disciplinario de primera instancia, al que la ley le ha dotado de amplia autonomía e independencia, se ajustó con plena subvención al ordenamiento jurídico, la sanción se impuso sin menoscabo del derecho al debido proceso del disciplinado (XXX), luego de hallar plenamente acreditadas: **i)** la comisión de la falta gravísima (art. 48 núm. 56 CDU), **ii)** la ilicitud sustancial de la conducta, (art 5º y 22 CDU) y la responsabilidad subjetiva del actor **iii)** (Art 13 y 42 CDU), con pruebas legal y oportunamente practicadas, y debidamente valoradas, (Art 128 y 130 CDU), como arriba se expuso con suficiencia.

la Jurisprudencia Administrativa como Constitucional más recientes, han reconocido la interpretación y aplicación de la ley, como un pleno ejercicio propio de la autonomía funcionalmente conferida al servidor que tiene el poder disciplinario; entonces cuando éste adopta las decisiones interpretando y aplicando la ley, siguiendo su propio criterio, y con fundamento en los elementos de juicio y probatorios aportados al proceso, el control de legalidad del acto sancionador no autoriza per sé, la imposición de un criterio de interpretación y valoración diferente; ello sólo es posible en los casos en los que la decisión desborde protuberantemente los límites que imponen la Constitución y la ley.

En consecuencia, las diferencias interpretativas entre lo expuesto en la decisión disciplinaria por parte del titular de la misma y la interpretación que adopte el procesado frente a los mismos asuntos probatorios, no constituyen por sí mismas razones suficientes para invalidar la decisión administrativa de primera instancia, así el hecho de que tal valoración no beneficie al recurrente, nada tiene que ver con la violación al debido proceso y al derecho de defensa.

Finalmente y en cuanto a la presunta indebida dosificación de la sanción argüida por la defensa, encuentra este despacho que las decisiones se adoptaron luego de la valoración integral y en

³¹Consejo De Estado Sala De Lo Contencioso Administrativo Sección Segunda Subsección A Consejero ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren Bogotá, D.C., once (11) de julio de dos mil trece (2013) Radicación número: 11001032500020110012100 (041311).

Continuación del Fallo por el cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primera instancia proferido dentro del expediente disciplinario No. 1704-01-2014-041.

conjunto de las pruebas arrimadas a la actuación, bajo una crítica razonada y proporcionada, respetando el debido proceso, el derecho de defensa y contradicción del encartado, por cuanto en el caso concreto, en el acápite de la sanción a imponer del fallo impugnado, se realizó por el despacho a-quo un análisis de los criterios valorativos para tal efecto previstos en el Artículo 47 de la Ley 734 de 2002³².

Al respecto señalo el despacho A-Quo:

“...El artículo 47 de la ley disciplinaria fija los criterios a tener en cuenta para determinar el término de duración de la inhabilidad, siendo relevantes para este despacho la ausencia de antecedentes del investigado; la diligencia y eficiencia demostrada en el desempeño del cargo según las evaluaciones de desempeño allegadas en audiencia y la confesión de la falta, circunstancias que favorecen el límite de la inhabilidad general a su favor, siendo así y en ejercicio del principio de proporcionalidad se impondrá al disciplinado - sanción de destitución e inhabilidad general para ejercer funciones públicas por el término de diez (10) años...”sic.

Visto lo anterior y atendiendo a que el propósito del derecho disciplinario es garantizar la buena marcha de la función pública, mediante la investigación y la eventual sanción de comportamientos que resulten nocivos para los fines y el buen desempeño de las entidades Estatales, también corresponde, como se hizo, al operador disciplinario evaluar y graduar mediante criterios objetivos y ponderados que respondan a la proporcionalidad y a la dignidad humana, una sanción ajustada a derecho.

Lo anterior con plena observancia del ordenamiento jurídico previamente determinado por el legislador a quien en virtud del principio de libertad de configuración normativa del que la misma Constitución le ha revestido y provisto³³, es el Poder o ente de orden Estatal y Constitucional llamado a determinar el plexo de las sanciones disciplinarias, como de sus inhabilidades y el término de las mismas, la cual ha sido para el caso administrativo disciplinario establecido en destitución e inhabilidad general para las faltas gravísimas dolosas o cometidas con culpa gravísima, según las voces de los artículos 42, 44 y 47 del CDU, en un mínimo de 10 años y en un máximo de 20, atendiendo a los criterios atenuantes o agravantes de la conducta sancionada

³² Ver folios 174 y 175 Cno 1.

³³ Artículo 150 de la Constitución Política de 1991: Corresponde al Congreso hacer las leyes.

Continuación del Fallo por el cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primera instancia proferido dentro del expediente disciplinario No. 1704-01-2014-041.

según sea el caso, previstos en dicha normatividad, motivo por el cual no corresponde a este despacho graduar la inhabilidad general de la que es acreedor el expedientado en la presente actuación disciplinaria, fuera de estos términos o máximas legales taxativamente señalados en la norma disciplinaria, como lo depreca el inconforme, al pretender que se gradué la inhabilidad de la falta a 5 años, sin que la norma disciplinaria a si lo disponga.

En ese orden de ideas, sobre la materialidad de la conducta asumida por el enjuiciado y sancionada en el fallo de primera instancia, no existe duda para este despacho, que la misma se encuentra ajustada a derecho y proporcionada a los hechos imputados en la sanción impuesta por la Sub Dirección Técnica Disciplinaria de la Agencia ITRC. Por lo anterior el cargo impugnado no prospera.

No cabe duda para la segunda instancia que el despacho instructor, recaudo las pruebas necesarias para demostrar en grado de certeza y más allá de toda duda razonable, la responsabilidad disciplinaria del señor (XXX), las analizo de acuerdo a las reglas propias de la lógica y la sana crítica, determino la tipicidad, la ilicitud sustancial y la culpabilidad y finalmente expuso de manera precisa y razonada los motivos por los cuales se debía sancionar al procesado.

Basten hasta aquí las consideraciones ut supra, para rechazar los argumentos de sustentación de la apelación, presentados por la defensa. Solo resta afirmar, haciendo eco del análisis probatorio realizado por el operador disciplinario de primer grado, que el procesado (XXX), incurrió en la falta disciplinaria objeto de acusación, razón por la cual deberá responder disciplinariamente por dicho comportamiento, tal como se expresará en la parte resolutive de esta providencia, al confirmar en su totalidad el fallo objeto de alzada.

En tal virtud, la Directora General de la UAE Agencia del Inspector general de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales – ITRC, en uso de sus atribuciones legales,

RESUELVE:

PRIMERO. RECHAZAR las razones de impugnación invocadas por el defensor (XXX), en representación del procesado (XXX), de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva del presente proveído.

Continuación del Fallo por el cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primera instancia proferido dentro del expediente disciplinario No. 1704-01-2014-041.

SEGUNDO. En consecuencia, **CONFIRMAR EN SU TOTALIDAD** el fallo sancionatorio de primera instancia proferido por el Subdirector Técnico de Investigaciones Disciplinarias de la UAE Agencia ITRC el pasado 19 de mayo de 2014.

TERCERO. NOTIFICAR el contenido de esta decisión a los sujetos procesales, de conformidad con las previsiones legales contenidas en los artículos 101,104 y 107 de la Ley 734 de 2002.

CUARTO. Contra la presente decisión no procede recurso alguno.

QUINTO. La presente decisión queda en firme el día de su suscripción, pero sus efectos jurídicos se surten a partir de la notificación, tal como lo dispone el inciso segundo del artículo 119 de la Ley 734 de 2002.

SEXTO. Una vez surtida la notificación del presente fallo, **REGISTRAR** la sanción disciplinaria ante la División de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación, según lo ordena el artículo 174 de la Ley 734 de 2002, en armonía con el artículo 48, numeral 57 de la misma norma.

SEPTIMO: REMITIR copia de la presente decisión al nominador del procesado, para que proceda a ejecutar la sanción impuesta, de conformidad con lo establecido en el numeral 3º y párrafo del artículo 172 del C. D. U.

OCTAVO. Ejecutoriada esta decisión y libradas las comunicaciones de rigor, **ARCHIVAR** el expediente.

CÓPIESE NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

CARMEN MARITZA GONZALEZ MANRIQUE

Directora General

Proyectó: Dr. Julian Andres Garcia Novoa

Continuación del Fallo por el cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo de primera instancia proferido dentro del expediente disciplinario No. 1704-01-2014-041.

Aprobó: Dr. (a) Carmen Maritza González M. – Directora General.